



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO/LEY 1437 DE 2011

El artículo 84 de la Ley 1437 de 2011, establece que el Silencio Administrativo Positivo se configura “Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso. El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este Código”.

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO/SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

En términos constitucionales se puede definir la figura del silencio administrativo como una herramienta que el legislador ha dispuesto para que el ciudadano pueda: i) hacer valer sus derechos ante la administración de justicia, en el caso del silencio administrativo negativo, por cuanto no puede quedar indefinidamente a la espera de una respuesta por parte del ente estatal encargado de resolverla, hecho que hace necesario crear un mecanismo para que pueda acudir ante la misma administración recurriendo el acto ficto o ante la jurisdicción o, ii) ver satisfechos sus derechos ante la omisión de la administración, en el caso del silencio administrativo positivo, en la medida en que el mutismo de aquella concreta en su cabeza un derecho. Sobre las opciones que tiene el ciudadano cuando opera el silencio administrativo negativo ha dicho esta Corporación en forma reiterada: “..., el administrado puede optar por acudir a la jurisdicción o por esperar una respuesta efectiva de la Administración, sin que esta última opción, que es un desarrollo del derecho de petición, pueda acarrearle consecuencias adversas, como sería la de que a partir del momento previsto para la operancia del silencio administrativo se contabilice el término de prescripción o de caducidad de la respectiva acción”. De esta manera, si bien se podría considerar que en el marco del Estado Social de Derecho la administración está en la obligación de dar respuesta oportuna, clara, concreta y de fondo a las solicitudes presentadas por los ciudadanos, en donde la consagración de una ficción sobre la negativa o aceptación de las peticiones pueden ser percibida como contraria a los postulados de la función pública y el respeto por los derechos fundamentales, si se tienen en cuenta que uno de los fines del Estado es garantizar los derechos consagrados en la Constitución y facilitar la participación de todos en las decisiones que lo afectan, artículo 2 constitucional; la Sala no duda en afirmar que esas presunciones resultan un instrumento adecuado para garantizar, entre otros, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, vulnerados por la omisión de la administración al no responder oportunamente los requerimientos elevados por los ciudadanos. Ficción que en los términos de nuestro ordenamiento no exime a la administración de absolver la solicitud, porque el derecho de petición sólo se satisface cuando el Estado profiriere respuestas claras, precisas y de fondo¹.

UNIDAD NORMATIVA/INTEGRACIÓN/SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

En el juicio de constitucionalidad dicha integración procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con otros contenidos jurídicos, que resulta imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones. Así mismo la Corte ha señalado que en aquellos casos en los que “el aparte demandado constituye una unidad jurídica o un todo inescindible en relación con el texto integral de dicha norma” y en los que “de declararse la inexequibilidad del referido segmento normativo la norma quedaría incompleta, sin sentido, porque básicamente éste es parte importante y esencial de la regulación que el legislador quiso hacer” procede efectuar dicha unidad normativa.

DERECHO DISCIPLINARIO/OBJETO DE PROTECCIÓN/SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

Dicho derecho está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones. En este sentido y dado que las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública².

¹ Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

² Referencia: expedientes D-3937 y D-3944

Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 3 (parcial), 5, 7, 13, 14 (parcial), 17 (parcial), 28 numeral 2° (parcial) y 4°, 30 (parcial), 32 (parcial), 44 numeral 1° (parcial) y parágrafo y 46 (parcial) de la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Unico”.



POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-245

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número del Proceso:	1704-01-2014-245
Número y fecha del fallo:	Resolución 17317-00030 del 16 de noviembre de 2016
Asunto:	Fallo de primera instancia
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio de primer instancia

RESOLUCIÓN No. 17317-00030 16 de noviembre de 2016

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-245

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Una vez evacuado el trámite correspondiente al procedimiento verbal dentro del proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2013-018, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

2. IDENTIDAD DE LOS INVESTIGADOS

XXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía número XXXXX expedida en Bucaramanga, y quien ingresó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN desde el 10 de diciembre de 1992, y para la época de la conducta investigada ocupaba el cargo de Auditora en el cargo de Gestor II Nivel 302 Grado 02 del Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización- Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

XXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXXXX expedida en Bucaramanga y quien de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso fungió como funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, desde el 18 de mayo de 2004 y para la época de la conducta investigada ocupaba el cargo de Gestor III Código 303 Grado 03 como Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización- Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

3. HECHOS

Fueron reseñados en el auto de citación a audiencia, de la siguiente forma:

<<Los hechos objeto de esta actuación disciplinaria tuvieron acaecimiento en la Dirección Seccional de Aduanas de Bucaramanga, de manera particular en el Grupo Interno de Trabajo Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la aludida seccional, entre el mes de enero de 2014 y el 1° de abril de la misma anualidad, habida cuenta que no se expidió acto administrativo de fondo dentro del expreso término establecido por la normatividad, al interior del expediente OC 2011 2013 2835, adelantado por la administración contra el usuario XXXXX, por haber incurrido en infracción administrativa, lo que a la postre generó la consolidación el silencio administrativo positivo.

En efecto, se ha establecido mediante la información suministrada por la propia administración a través de la Resolución 2183 del 29 de julio de 2014, por el cual la División Jurídica -GIT Vía Gubernativa de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, resolvió el recurso de reconsideración formulado en contra de la Resolución sanción 1556 del 29 de abril de 2014, que en desarrollo del expediente adelantado a XXXXX Y/O XXXXX, la administración, a través de la División de Fiscalización y en forma particular del GIT de Investigaciones Aduaneras y de Control Cambiario, ordenó la apertura de investigación por Operación de Contrabando al usuario aduanero arriba reseñado, mediante auto 4436 del 6 de diciembre de 2013.

La apertura formal del expediente se dio con auto del 16 de diciembre y el área en comento, mediante auto del 20 de diciembre solicitó al importador colocar a disposición de la DIAN la mercancía, consistente en productos químicos traídos de China. Para el 31 de diciembre de 2013, la administración, formuló REA o Requerimiento Especial Aduanero al usuario, mediante el cual propuso sanción por no haber sido puesta a disposición de la administración la mercancía.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-245

Es a partir de esta etapa de la actuación administrativa, que empieza a vislumbrarse la situación con contenido disciplinario, toda vez que estando dentro del término legal, el usuario dio respuesta al requerimiento especial mediante escrito radicado el 24 de enero de 2014 en el Nivel Central y remitido a la Seccional el 30 de ese mismo mes y año.

Así las cosas y en consideración a que el 18 de febrero se desfijó el estado mediante el cual fue notificado el auto de 7 de febrero de 2014, por el cual se denegaron las pruebas solicitadas por el usuario y que éste no hizo uso de su derecho de presentar recurso de reposición, resultaba procedente dar aplicación al término regulado en el inciso segundo del artículo 512, el cual le otorgó a la administración un plazo de cuarenta y cinco (45) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía, a partir del día siguiente a la fecha en la que se radicó la objeción a la aprehensión o, como en este caso, a la respuesta del requerimiento especial aduanero.

Con base en la anterior disposición y dadas las características temporales del caso en particular, el término de cuarenta y cinco (45) días para que la administración decidiera de fondo, inició el 27 de enero de 2014 y culminó el 1° de abril de 2014; sin embargo, el área que tenía a su cargo dicho trámite, es decir el GIT de Investigaciones Aduaneras y de Control Cambiario de la División de Fiscalización, sólo remitió el expediente a la División de Fiscalización hasta el 31 de marzo de 2014, es decir a un (1) día del vencimiento.

Por consiguiente, cuando la División de Liquidación profirió la Resolución Sanción cuando no es posible aprehender la mercancía, mediante acto administrativo No 1556 del 29 de abril de 2014, el término ya había vencido, lo cual determinó que la División Jurídica en desarrollo de la vía gubernativa tuviese que declarar el silencio administrativo positivo.»

4. CARGO FORMULADO

Por medio del Auto No. 1741200016 de fecha 24 de octubre de 2016, esta Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la UAE ITRC formuló pliego de cargos a los investigado XXXXX y XXXXX, así:

<<XXXXX, quien fuera designada como auditora mediante auto No 02385 del 16 de diciembre de 2013, para la gestión del expediente administrativo OC 2011-2013-002835 iniciado al usuario aduanero XXXXX Y/O XXXXX y cuyo trámite adelantaba el Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, presuntamente dio lugar al silencio administrativo positivo, por inobservancia y omisión en la aplicación y cuidadoso seguimiento del término establecido en el inciso segundo del artículo 512 del Estatuto Aduanero, a la luz de lo dispuesto en el artículo 519 de la normatividad en comento.

Tal circunstancia se suscitó por cuanto, no obstante que la administración disponía de cuarenta y cinco días para proferir decisión de fondo, término que iniciaba el 27 de enero de 2014 y culminaba el 1° de abril de 2014, el expediente sólo fue remitido el 31 de marzo de 2014 a la División de Liquidación, a través de auto proyectado por la disciplinada, razón por la cual la resolución sanción que decidió de fondo sólo pudo ser proferido el 29 de abril del mismo año, cuando el término ya había vencido.

Con base en lo anterior, se habría dado configuración al silencio administrativo positivo, conforme a la descripción del numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2012.

XXXXX, en su condición de Jefe de Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, designado como Supervisor mediante auto No 02385 del 16 de diciembre de 2013, para la gestión del expediente administrativo OC 2011-2013002835, iniciado al usuario aduanero XXXXX Y/O XXXXX y cuyo trámite adelantaba el grupo a su cargo, presuntamente dio el lugar al silencio administrativo positivo, por inobservancia y omisión en la aplicación y cuidadoso seguimiento del término establecido en el inciso segundo del artículo 512 del Estatuto Aduanero, a la luz de lo dispuesto en el artículo 519 de la normatividad en comento.

Tal circunstancia se suscitó por cuanto no obstante que la administración disponía de cuarenta y cinco días para proferir decisión de fondo, término que iniciaba el 27 de enero de 2014 y culminaba el 1° de abril de 2014, el expediente sólo fue remitido el 31 de marzo de 2014 a la División de Liquidación, a través de auto que fue suscrito por el disciplinado, razón por la cual la Resolución sanción que decidió de fondo sólo pudo ser proferida el 29 de abril del mismo año, cuando el término ya había vencido.

Con base en lo anterior, se habría dado configuración al silencio administrativo positivo, conforme a la descripción del numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2012.>>

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-245

La situación fáctica contenida en el cargo anterior se encuadró en la presunta realización de la falta gravísima, establecida en el numeral 35 del artículo 48 del Código Disciplinario Único.

5. ARGUMENTOS DE DEFENSA:
VERSIÓN LIBRE Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

XXXXX, manifestó en versión libre presentada ante este despacho el día 14 de octubre de 2015, que para la época de los hechos desempeñaba funciones de Auditora de Fondo en Control Posterior, en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga. Sobre los hechos objeto de investigación señaló que el expediente en el cual se declaró el silencio administrativo, tiene antecedentes que surgen en al año 2012, pues contenía dos declaraciones de importación, junto con una denuncia en la cual se informaba que el importador estaba pagando menos fletes de los que debía pagar.

Agregó que adelantando el proceso aduanero no encontró diferencias relacionadas con el valor de los fletes, pero sí evidencio que la empresa Multiquimicos importaba una mercancía que en facturas, documento de transporte, manifiesto de carga, y en certificado de origen se denominaba Cloruro de Calcio, y que el importador nacionalizó como Hipoclorito de Calcio, situación por lo cual la versionada manifiesta haber requerido al importador para que pusiera a disposición la mercancía (Hipoclorito de Calcio) por ser mercancía no presentada.

Señaló que teniendo en cuenta que el importador no puso a disposición de la DIAN la mercancía, se dispuso la apertura del expediente OC, por concepto de Operación de Contrabando, y se profiere "Requerimiento Especial Aduanero (REA) por no colocar a disposición la mercancía" el día 31 de diciembre de 2013, día en que la versionada manifiesta haber salido de vacaciones, regresando de las misma el 24 de enero de 2014. Agrega que en el expediente reposan documentos en los cuales consta que el importador el 8 de enero de 2014 puso a disposición cinco mil kilos de la mercancía en Almagrario, y posterior a eso se evidencia un oficio enviado por su jefe, para la fecha de los hechos el señor XXXXX, de fecha 20 de enero de 2014, en el cual se informa que se envían muestras de la sustancia puesta a disposición por el importador, a la Coordinación de Servicios de Aduanas de Bogotá.

También indica que el 3 de febrero de 2014 recibió respuesta del importador al Requerimiento Aduanero Especial, donde según la versionada, no se alude nada sobre la entrega de la mercancía ante la DIAN; motivo por el cual niega pruebas con fundamento en conceptos y le confirma el REA. Adicionalmente, manifestó que posteriormente su jefe el señor XXXXX, le manifiesta que el importador sí puso a disposición la mercancía y que esta estaba en pruebas de laboratorio, motivo por el cual tenía que esperar a que llegara la prueba del laboratorio porque de lo contrario no se podía continuar con el proceso, y se tenían dos opciones o seguir con el proceso sancionatorio o aperturar otro para la definición de situación jurídica. (Siempre se mantuvo el procedimiento de sanción, aun estado la muestra en el laboratorio)

Sobre la demora de los resultados del laboratorio, señaló que se tenía conocimiento que esas pruebas eran demoradas, y que sus resultados de son de un día para otro, y reitera que es testigo de que su jefe el señor XXXXX, en varias ocasiones llamó a Bogotá, para solicitar información, y ella manifiesta haber llamado también. Respuesta que llego según la versionada hasta el 19 de marzo de 2014 por medio de correo electrónico, situación que permitió evidenciar que el importador no había puesto a disposición la totalidad de la mercancía, habiendo puesto nominalmente 10 toneladas y entrando 5 toneladas, de las cuales solo 752 era Hipoclorito de Calcio.

que con la información recibida se realizaría el informe a liquidación según la versionada el día 25 de marzo de 2015, para el correspondiente traslado de proceso a liquidación que se efectuaría hasta el 27 de marzo de 2014, fecha en la cual la investigada no tendría más el expediente, sin embargo, la remisión del expediente quedaría con fecha de 31 de marzo de 2014.

Asegura que ella y su jefe estaban tranquilos pues, en su sentir, la mercancía no estaba amparada en documento manifiesto alguno, era una mercancía que no podía ser legalizada, y sobre esa mercancía no procedería un silencio administrativo, citando que "No habrá Silencio Administrativo Positivo, cuando no se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión. Artículo 519 del Decreto 2685 de 1999". Lo anterior aunado a que el Hipoclorito de Calcio es una mercancía que no puede ser legalizada porque no fue presentada ante la autoridad aduanera, ya que no venía relacionada en ningún documento soporte. Reitera que recibió la respuesta del laboratorio el 19 de marzo de 2014, y de acuerdo a eso hizo los cálculos para informarle al grupo operativo lo que se debía aprehender, y el 27 de marzo realizo el informe y simultáneamente el auto de traslado, el cual salió con fecha 31 de marzo de 2014.

XXXXX, manifestó en versión libre presentada ante este despacho en audiencia del día 05 de diciembre de

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-245

2014, que en primer lugar quería hacer referencia a el auto de archivo proferido por la División de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, por el cual se trasladó una investigación a sanción, por considerarlo así el competente, investigación por sanción, en la cual se le solicita al importador mediante un requerimiento ordinario que este pusiera a disposición la mercancía objeto de investigación, siendo el plazo máximo para efectuar dicha entrega el día 29 de diciembre de 2013, no cumpliendo el importador con dicho plazo y dando lugar así a la expedición del Requerimiento Especial aduanero de fecha 31 de diciembre de 2014.

Por otra parte, aduce que posterior a la expedición del Requerimiento Aduanero Especial, el día 8 de enero de 2014, el importador hace entrega de la mercancía ante la DIAN, en las bodegas designadas para tal fin, esto es, XXXXX., a través del acta de hechos No. 5, hecho que según el versionado cambiaría el rumbo del proceso administrativo sancionatorio, dejando carente de supuesto factico de la investigación, siendo el objeto de la misma la solicitud de entrega de la mercancía, y habiéndose cumplido, no habría razón de ser del proceso sancionatorio.

Indica el investigado que posteriormente a la entrega de la mercancía por parte del importador, se debía solicitar al laboratorio de Aduanas de la DIAN, el cual se encuentra ubicado en Bogotá, que se determinara dos situaciones, la primera de ellas la evidenciada en el oficio con radicado 481 del 20 de enero de 2014, en el cual se solicitaba la práctica del examen físico químico a las muestras remitidas por la DIAN, que corresponde a Hipoclorito de Calcio y las cuales fueron puestas a disposición conforme al requerimiento ordinario N. 449 del 20 de diciembre de 2013, expido por el grupo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la División de Fiscalización de Bucaramanga, con el objeto de continuar con el proceso de definición de la situación jurídica, y una vez obtenidos los resultados del análisis, se procediera a enviar copia de ellos a la oficina de arancel para que se suministrara la clasificación arancelaria que correspondía.

Sobre el Acta No. 5 de fecha 8 de enero de 2014, señala el versionado que esta fue citada en la resolución sanción en el folio No. 8 y en la resolución que declara el silencio administrativo positivo en el folio 8. Manifiesta que la consecuencia jurídica derivadas de la desaparición del supuesto factico, es la desaparición del procedimiento administrativo sancionatorio, e inicia el procedimiento administrativo de definición de situación jurídica de la mercancía.

En lo atinente a la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero señaló que esta no fue radicada en la DIAN Bucaramanga, si no por el contrario en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

Nivel central, el día 24 de enero de 2014, siendo recibido en la oficina de documentación de la DIAN de Bucaramanga el 30 de enero de 2014, el 31 de enero es trasladado a la secretaria de Fiscalización Seccional Bucaramanga, y solo hasta el 3 de febrero tienen conocimiento de esta respuesta los investigados, posteriormente a eso señala que se expide auto que niega pruebas.

Adicionalmente, que la respuesta del laboratorio fue recibida el día 20 de marzo de 2014, dirigida al señor XXXXX, en calidad de jefe de la Coordinación del Servicio de Arancel de Aduanas, desconociendo el investigado que tener conocimiento del mencionado documento, sino hasta el día 27 de marzo de 2014, que el versionado señala recibir un correo electrónico.

Para finalizar, arguye que desde el día 27 al día 31 del mes de marzo de 2014, tuvo programadas diferentes actividades de carácter laboral, las cuales son soportadas en los folios 770 al 785, documentos en los cuales se observa certificado de capacitación, correos electrónicos y formatos de presentación de diferentes capacitaciones que debían ser ofrecidas por el investigado; adicionalmente señala el investigado que como Jefe del Grupo de Trabajo que el señor XXXXX lideraba tres procedimientos aduaneros, tres procedimientos cambiarios y adicionalmente tenía que capacitar a los funcionarios de la policía fiscal y aduanera.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN APODERADO DE LA INVESTIGADA CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ ARENAS

Los alegatos de conclusión presentados por el apoderado de la investigada XXXXX, se fundamentan en la carencia de negligencia por parte de la antes mencionada funcionaria, siendo que en su sentir y de acuerdo a los documentos que obran en el expediente como autos y resolución fueron expedidos con todos los requisitos de Ley, y con la supervisión y vigilancia de su jefe señor XXXXX.

Señala como fundamental para la investigación el tiempo transcurrido dentro del proceso OC 2011 2013 2385, en el cual el Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización- Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, estuvo a la espera el resultado de las pruebas físico químicas, tendientes a demostrar el compuesto de la mercancía entregada por el importador XXXXX Y/O XXXXX a la DIAN, teniendo en cuenta que este resultado cambiaría el rumbo

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-245

de la investigación adelantada por los funcionarios investigados, siendo el hecho generador de un posible cambio de procedimiento como lo es un proceso sancionatorio y un proceso de definición de la situación jurídica de una mercancía. Siendo ese el objeto principal de la investigación por parte de la Agencia ITRC, el cual tendría como fin revisar las causas que llevaron a la administración a declarar el silencio administrativo positivo.

Sobre lo anterior, señala que el despacho no puede endilgar como una causa de la ocurrencia del silencio administrativo positivo, a ninguna de las conductas de los funcionarios investigados, siendo que el expediente nunca estuvo en estado de inactividad, toda vez que el único periodo de espera dentro del mismo fue el transcurrido mientras se allegaba la respuesta del examen físico químico que era totalmente necesario para la continuación de la investigación siendo relevante saber si el material entregado por el importador era HIPOCLORITO DE CALCIO o CLORURO DE CALCIO, materiales que tienen un tratamiento diferente al momento de la importación. Hecho este del tiempo que saldría de la esfera de la responsabilidad de los investigados, siendo el paso del tiempo una situación objetiva que nadie puede desvirtuar.

Para finalizar, aduce que prueba de la diligencia de la funcionaria XXXXX, dentro de" las actuaciones adelantadas dentro del proceso de aduanero OC 2011 2013 2385, son los documentos obrantes dentro del mismo, los cuales fueron proferidos de manera idónea y dentro de los términos que legalmente correspondían, no obrando prueba alguna que logre demostrar la existencia de una responsabilidad de tipo disciplinario, por parte de los funcionarios investigados y particularmente la funcionaria XXXXX.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN APODERADO DEL INVESTIGADO XXXXX

El primer punto objeto de sustentación por la defensa del funcionario XXXXX está relacionado con la tipificación de la conducta que da configuración a la investigación disciplinaria adelantada por este despacho, resaltando que el simple conteo forma de los días permitiría determinar que existió la configuración del silencio administrativo positivo, aun mas resultaría temerario y carente de todo sustento factico, que se argumente que el silencio administrativo no ocurrió, cuando sería lo realmente importante analizar si fue por la acción u omisión de los dos funcionarios disciplinarios.

Por lo anterior, solicita tener en cuenta los hechos ocurridos durante la ejecución del proceso administrativo sancionatorio, como lo es la inicial no entrega de la mercancía por parte del importador, motivo por el cual se expide el requerimiento especial aduanero, iniciando así el procedimiento administrativo sancionatorio de manera legal y con toda regla, señala que el 08 de enero 2014, el importador pone a disposición de la DIAN, la mercancía solicitada, siendo este el motivo por el cual desaparecería el supuesto factico de la norma el cual según la defensa daría lugar a la sanción.

Indica la apoderada que durante el lapso que duro el proceso aduanero, no es posible que algún funcionario aduanero tomara una decisión, toda vez que, hasta el 27 de marzo de 2014, es cuando se pone de presente que la mercancía que el importador señaló que era HIPOCLORITO DE CALCIO, no lo era, motivo por el cual se procedió a la aprehensión y decomiso de la mercancía. Adicionalmente, que en el hipotético caso en que el laboratorio hubiera indicado que las 28 muestras correspondían a HIPOCLORITO DE CALCIO, el expediente hubiese tenido que archivar por improcedencia de la sanción.

Por otra parte, que para que exista la falta requiere que se predique ilicitud sustancial sin justificación alguna, la defesa que efectivamente existió una afectación al deber funcional de la DIAN, sin que este pueda ser imputable a los funcionarios de la DIAN, teniendo en cuenta que ninguna acción u omisión de ellos fue negligente y descuidada, no habiendo habido abandono del expediente, ni de las gestiones; reitera él tampoco tiene como propósito endilgarle la responsabilidad al laboratorio de aduanas, siendo que se tiene pleno conocimiento que este atiende a 46 direcciones seccionales. Adicionalmente, señala que contemplando lo señalado por la norma en cuanto a la ilicitud sustancial, este viene acompañado de sin justificación alguna, hecho que no es el percibido en el caso objeto de investigación, toda vez que aquí era absolutamente necesario el análisis por parte del laboratorio por tratarse de un producto químico, el cual siempre requiere de un pronunciamiento técnico.

También señala la apoderada que la falta también se configuraría por incumplimiento de los deberes, extralimitaciones en el ejercicio de los derechos y las funciones, haber incurrido en alguna de las prohibiciones, o haber violado el régimen de incompatibilidades e impedimentos y conflictos de interés, cuatro conductas que la defensa considera no se pueden predicar en el caso objeto de investigación, y por el contrario la defensa considera que demostró que se cumplieron todos los deberes.

Sobre el lapso transcurrido desde que el importador hace entrega de la mercancía esto es el 8 de enero de 2014, hasta la fecha en la cual se envían las muestras al laboratorio, no puede considerarse como inactividad, sino el procedimiento necesario que se requería para tal procedimiento.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-245

Para finalizar, la apoderada hace referencia a las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, dentro de las cuales se encuentra la de dar estricto cumplimiento a un deber legal o constitucional de mayor importancia que el sacrificado, situación que se hubiese dado si los disciplinados hubieran omitido la toma de muestras, remitir las muestras con la correspondiente solicitud a las áreas pertinentes.

6. PRUEBAS**6.1. Documentales**

- Copia de la Resolución No 2183 del 29 de julio de 2014, por medio del cual la División de Gestión Jurídica -GIT Vía Gubernativa de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por XXXXX Y/O XXXXX contra la "Resolución Sanción cuando no es posible aprehender la mercancía", expedido por la División de Liquidación y cuyo número de radicado corresponde al 1556 del 29 de abril de 2014.

En la copia del documento la administración reconoce la presencia del silencio administrativo positivo por no haber sido proferido decisión de fondo dentro del expediente administrativo OC 2011 2013 2385 (folios 6 y siguientes del cuaderno original uno), en el término establecido por el inciso del artículo 512 del Estatuto Aduanero.

Copia íntegra del expediente administrativo OC-2011-2013-2835, incorporada al expediente en desarrollo de la inspección administrativa efectuada por el Despacho en la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga el 24 de junio de 2014 (folios 38 y siguientes del cuaderno original uno, hasta el folio 243 inclusive y del folio 249 hasta el folio 463 del cuaderno original número dos).

Mediante la revisión ponderada de la documentación en comento resulta posible efectuar la trazabilidad de la actuación administrativa, mediante el seguimiento cronológico de las diferentes actividades y decisiones adelantadas en la misma.

De esta forma es posible evidenciar que por la Denuncia de Tercero No 199 del 6 de septiembre de 2011, la administración a través de la División de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga presentó el 15 de febrero de 2013 un Plan de Auditoría suscrito por XXXXX en su condición de auditora y XXXXX como Jefe del GIT de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario (folio 56), para la correspondiente actuación a adelantar al usuario XXXXX, previo auto de apertura fechado el 11 de septiembre de 2011.

Luego de haber sido incorporada información pertinente y de la formulación de algunos requerimientos, el GIT Investigaciones Aduanera y Control Cambiario expidió el Requerimiento No 00367 del 17 de octubre de 2013, con el fin de que el usuario pusiera a disposición la mercancía de manera inmediata para su legalización, decisión suscrita por el Jefe del área en ese entonces XXXXX y proyectado por XXXXX (folios 202 y siguientes)

Posteriormente, mediante auto del 6 de diciembre de 2013, proyectado por XXXXX y suscrito por XXXXX como Jefe del GIT, se profirió auto de archivo del expediente VG 2010 2011 02528 y ordenó la apertura de la investigación por operación de contrabando a nombre de XXXXX al no declarar mercancía importada de China, consistente en el químico CLORURO DE CALCIO (folios 212 y siguientes). Es con base en esta decisión que se abrió por parte de la División de Fiscalización y mediante auto del 16 de diciembre de 2013, el expediente OC 2011 2013 02835, en el que expresamente se designó a XXXXX y a XXXXX como supervisor (folio 222). A continuación, mediante auto No 0049 del 20 de diciembre de 2013, proyectado por XXXXX, el Jefe del GIT Investigaciones Aduanera y Control Cambiario, XXXXX, requirió al usuario XXXXX Y/O XXXXX, para que colocara a disposición de la administración la mercancía (folio 224) y cuya descripción se encontraba en la declaración de importación 23847012644553 del 5 de enero de 2011, imponiendo un plazo de seis días desde el recibo de la comunicación.

Para el 31 de diciembre de 2013 el Jefe del GIT Investigaciones Aduanera y Control Cambiario, XXXXX suscribió el Requerimiento Especial Aduanero por imposibilidad de aprehender la mercancía, número 0453; acto administrativo proyectado por XXXXX, por un valor de \$93.043.926, debido a que el usuario XXXXX no colocó a disposición de la administración la mercancía en el plazo otorgado (folios 236 y siguientes).

A continuación, el usuario a través de apoderado presentó respuesta al REA del 31 de diciembre mediante escrito radicado el 24 de enero de 2014, adelantando dicha actuación en término, por lo que fue remitido a Bucaramanga desde Bogotá donde se recibió dicha respuesta (folios 250 y siguientes). Así las cosas, la administración, a través del GIT Investigaciones Aduanera y Control Cambiario, profirió Acto Administrativo No

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-245

201 del 7 de febrero de 2014, denegó las pruebas solicitadas por el usuario en su respuesta (folio 268); decisión proyectada por XXXXX y aprobada por XXXXX, como jefe del área respectiva.

Con base en dichas circunstancias, el término de cuarenta y cinco (45) para decidir de fondo comenzaba a agotarse a partir del 27 de enero, según las previsiones del artículo 512, inciso segundo, habida cuenta que se habían denegado las pruebas solicitadas por el usuario.

Para el 20 de enero de 2014, el Jefe del GIT Investigaciones Aduanera y Control Cambiario, XXXXX, solicitó a la Coordinación de los Servicios de Laboratorio de Aduanas, análisis físico-químico de la mercancía que había sido dispuesta finalmente por el usuario el 3 de enero de 2014, es decir con posterioridad al REA del 31 de diciembre (folio 282), recibiendo los resultados mediante correo del 19 de marzo de 2014 (folio 286), del cual se concluyó que por lo menos parte de la mercancía nacionalizada no correspondió con la que fuera amparada en los documentos soportes por corresponder a dos compuestos químicos totalmente diferentes; sin embargo sólo hasta el 25 de marzo de 2014 y el 27 del mismo mes y año, se informó sobre los resultados del examen y se elaboró informe sobre el requerimiento especial respectivamente (folios 293 y siguientes), los cuales fueron suscritos por EDWAR AVENDAÑO BAUTISTA y proyectados, en lo que respecta a este último por XXXXX.

Finalmente, el Jefe del GIT Investigaciones Aduanera y Control Cambiario, XXXXX, remitió el 31 de marzo de 2014, mediante Auto de Traslado No 000857, el expediente OC-2011-2013-2835 a la División de Gestión de Liquidación; área que expidió la resolución sanción el 29 de abril de 2014, es decir cuando había vencido el término establecido en el artículo 512, inciso segundo.

- A folios 472 y siguientes se incorporó copia del Comité Seccional de Recursos Jurídicos celebrado en la Dirección de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, División de Gestión Jurídica, el 28 de julio de 2014, en el cual se aprobó, entre otros, el proyecto que resolvió el recurso de reconsideración presentado por XXXXX contra la Resolución Sanción No 1556 del 29 de abril de 2014, por la cual se declaró el silencio administrativo y se revocó la determinación formulada en el acto administrativo.

- Mediante la inspección administrativa adelantada en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga el 25 de junio de 2015, se pudo incorporar los siguientes documentos (folios 480 y siguientes):
-Copia de la Planilla Múltiple de Remisión mediante la cual fue enviado el expediente OC 201120130002835 el día 2 de abril de 2014 desde la División de Fiscalización a la División de Liquidación (folio 486).

-Copia del Acta de Reparto efectuado al interior de la División de Liquidación, mediante la cual fue asignado el expediente el 3 de abril de 2014 a XXXXX.

Con base en estos documentos, es posible avizorar que el conocimiento que tuvo la División de Liquidación del expediente adelantado a XXXXX, se consolidó con posterioridad a la fecha de vencimiento del término para decidir de fondo, es decir, luego del 1 de abril de 2014.

- En diligencia de inspección administrativa efectuada en la Subdirección de Historias Laborales de la UAE DIAN el 26 de junio de 2015, fueron incorporadas copias de los extractos de las hojas de vida de los funcionarios que posteriormente fueran vinculados a la actuación disciplinaria a través de la formulación del auto de apertura de investigación respectivo, estableciéndose su condición de sujetos disciplinables por ostentar la calidad de servidores públicos (folios 489 y siguientes).

- A partir del folio 613 fueron incorporadas las certificaciones laborales de los servidores públicos vinculados a la actuación disciplinaria.

- Finalmente, la prueba documental se complementó con los registros incorporados al expediente y que fueron recaudados durante la diligencia de inspección administrativa efectuada en las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, siendo procedente acotar la copia del Acta de Reparto No 363 del 16 de diciembre de 2013, donde se asignó a la servidora XXXXX, como auditora del expediente OC 2011 2013 0002835; acta suscrita entre otros por el Jefe del GIT de Investigaciones Aduanera y Control Cambiario, XXXXX.

6.2 Testimonios

XXXXX, abogada que presta sus servicios en el área de Vía Gubernativa como jefe de grupo, manifestó sobre los hechos que el acto sancionatorio proferido por la División de Liquidación dentro del expediente OC 2011 2013 0002835 fue revocado, previa consulta con el Comité Jurídico, por darse los presupuestos para la declaración del silencio administrativo positivo, ya que en el caso en particular la decisión de fondo debía haber

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-245

sido proferida dentro del término cuyo vencimiento era el 1 de abril.

XXXXX, abogada del área de Vía Gubernativa, manifestó que le correspondió el análisis del recurso de reconsideración interpuesto por el usuario aduanero. Adujo que el 23 de julio de 2014 y previa a una solicitud ante el XXXXX se recibió una respuesta por parte de dicha entidad en la que se informó que no se requería de su autorización para la importación del químico hipoclorito de calcio. Ahora, ante la solicitud del recurrente se elevaron consultas con diferentes niveles de la administración, sin embargo, no se halló otra salida diferente a la de la declaratoria del silencio administrativo, por lo que se tomó la respectiva decisión. Agregó que al caso le era aplicable el artículo 512 por lo que con base en dicha norma y tomando el término de cuarenta y cinco (45) días, el término para proferir decisión de fondo venció el 1 de abril, sin embargo, la resolución sanción sólo fue notificada hasta el 2 de mayo de 2014.

XXXXX, Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, manifestó durante el testimonio recibido durante la diligencia de Inspección Administrativa allí adelantada, las circunstancias que rodean el reparto y la carga laboral en el área a su cargo.

Es a partir de la lectura del recado probatorio reseñado, donde resulta factible, a través de un análisis ponderado e integral de los medios descritos que resulta factible concluir que se está, en forma certera, ante la configuración del silencio administrativo positivo, por cuenta de la inobservancia del término establecido en el artículo 512, inciso segundo del Estatuto Aduanero, norma que encuentra su complemento en el artículo 519 que de manera expresa estipula la generación de dicho fenómeno por el incumplimiento de los perentorios términos establecidos en el respectivo capítulo.

Para el efecto, opera como fuente de suficiente ilustración el acervo documental, particularmente concentrado en las copias obtenidas del expediente administrativo en ejercicio de las inspecciones administrativas adelantadas por esta Subdirección, y del cual resultan diáfanos todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que caracterizaron la consolidación de la falta.

Es así como, *prima facie*, fue posible establecer que la inobservancia de los términos legales, que finalmente determinaron la consolidación del silencio administrativo positivo, se generó en la División de Fiscalización y de manera específica en el GIT de Investigaciones Aduanera y Control Cambiario, habida cuenta que, de acuerdo con la dinámica de la normativa procedimental establecida en el artículo 512, el término con el que contaba la administración para decidir de fondo, atendiendo el hecho que se denegó las pruebas solicitadas por el usuario en el escrito de respuesta al Requerimiento Especial Aduanero y que contra esta decisión no se interpuso recurso alguno, era de cuarenta y cinco (45) días a partir del día hábil siguiente a la presentación o radicación de dicha respuesta. Es así como no obstante el término iniciara el 27 de enero de 2014 y venciera el 1 de abril del mismo año, el expediente fue remitido al área de Liquidación sólo hasta el 31 de marzo, por lo que ya resultaba menos que imposible expedir y notificar la resolución de liquidación al usuario en un (1) día.

En consecuencia, la prueba recopilada hasta este momento es concluyente al definir los siguientes aspectos:

Primero, la administración estaba compelida a cumplir los términos perentorios establecidos por la normatividad aduanera que, para el caso particular, se circunscribía a las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 512; es decir cuarenta y cinco días (45) a partir del día hábil siguiente a la presentación del escrito de respuesta presentada por el usuario.

Segundo, el término para el caso en concreto y según las condiciones de la norma mencionada en precedencia, inició el 27 de enero de 2014 y culminó del 1 de abril del mismo año; interregno en el cual la administración debió haber proferido decisión de fondo.

Tercero, no obstante, el efectivo inicio del término en la fecha arriba mencionada y de la perentoriedad del mismo, sólo hasta el 31 de marzo de 2014, la División de Fiscalización a través del GIT Investigaciones Aduanera y Control Cambiario, remitió el expediente a la División de Liquidación para la formulación de la resolución de sanción por mercancía sin aprehender, de tal forma que cuando fue efectuado el reparto del mismo a esta última hacia el 3 de abril de 2014, el término para decidir de fondo ya había vencido, por lo que el área de Vía Gubernativa, al resolver el recurso impetrado por el usuario, no tuvo otro remedio diferente que declarar el silencio administrativo positivo.

Cuarto, se evidencia que el término se consolidó durante el tiempo en que el expediente OC 2011 2013 0002835 estuvo a cargo del GIT Investigaciones Aduanera y Control Cambiario, gestión que fue asignada a una auditora de dicha área, con la supervisión del Jefe de la misma.

Quinto, con base en la anterior consideración, resulta posible establecer que la generación del silencio administrativo por inobservancia del término establecido en el artículo 512, inciso segundo del Estatuto

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-245

Aduanero, se consolidó estando el expediente administrativo OC 2011 2013 0002835 a cargo del GIT Investigaciones Aduanera y Control Cambiario, de manera específica bajo la gestión de la servidora pública XXXXX, quien fuera designada como auditora del mismo, tal y como lo estableció el auto de apertura No 02835 del 16 de diciembre de 2013 y por XXXXX, en su condición de Jefe del GIT de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario, quien fuera designado en dicho acto como supervisor, tal y como obra en el documento cuya copia obra a folio 222.

A partir de esta actuación, los servidores públicos en mención, ejercieron y adelantaron las actividades propias de operadores aduaneros, habida cuenta que, con posterioridad al auto de apertura arriba reseñado, se expidió el acto administrativo 0049 del 20 de diciembre de 2013, por el cual se requirió al usuario a fin de que pusiera a disposición de la administración la mercancía objeto de investigación; decisión proyectada y firmada, respectivamente, por XXXXX y XXXXX. Luego, los aludidos servidores públicos también participaron en la expedición de los actos administrativos números 0453 del 31 de diciembre de 2013 y 201 del 7 de febrero de 2014, consistiendo el primero de los mencionados en el Requerimiento Especial Aduanero formulado contra el usuario a XXXXX Y/O XXXXX, con sanción por \$93.043.026, y el segundo, en el auto que denegó las pruebas solicitadas por el usuario aduanero en la respuesta al requerimiento, decisión que en atención a los parámetros del artículo 512 servía para determinar el término con el que contaba la administración para decidir de fondo.

Finalmente, fue elaborado el auto de traslado, previos los informes elaborados por los servidores en mención, siendo suscrito el 31 de marzo de 2014 para su remisión a la División de Liquidación, es decir a un día del vencimiento del artículo 512, inciso segundo del estatuto aduanero; auto que, al igual que los reseñados en párrafos precedentes, fue proyectado por XXXXX y suscrito por XXXXX.

Huelga concluir que las circunstancias en las que se generó la falta disciplinaria, es decir el dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo, se consolidaron, según el acervo recaudado hasta este momento, estando el expediente administrativo a cargo de los servidores públicos XXXXX y XXXXX, en su condición de auditor^a y supervisor de la gestión, respectivamente.

7. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA:**RAZONES DE LA DECISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN QUE SE BASA****7.1. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA:**

Este Despacho es competente para proferir el fallo de primera instancia dentro de la presente investigación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con las previsiones del Decreto 4173 del 3 de noviembre de 2011.

En atención a lo ordenado en el Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, cuya apreciación debe corresponder a las reglas de la sana crítica, según lo establece el Artículo 141 ibídem.

De igual manera, deben reunirse de manera conjunta los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, los cuales es menester se encuentren debidamente acreditados dentro del sumario a partir de elementos de prueba legalmente allegados al proceso.

7.2. DEL CASO OBJETO DE ANÁLISIS**7.2.1. Del marco legal**

El contexto normativo en el cual se sitúa el deber funcional sobre el que gira este análisis, se enmarca en el procedimiento específicamente regulado por el Estatuto Aduanero para que la administración se pronuncie de fondo en trámites como el de que decide de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprendida y para expedir el acto administrativo que decide de fondo sobre una sanción, caso como el que atañe a esta actuación disciplinaria.

En efecto, el Inciso segundo, del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 20 del Decreto 4431 de 2004, cuando establece que:

“Artículo 512. Acto administrativo que decide de fondo. Vencido el término previsto en el inciso primero del artículo 505-1 del presente Decreto o el término previsto en el inciso segundo del artículo 510 sin que se

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-245

hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero, la autoridad aduanera dispondrá de quince (15) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida, mediante resolución motivada y de treinta (30) días para expedir el acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la Liquidación Oficial o el archivo del expediente, si a ello hubiere lugar"

"INC. 2° Modificado. D 2557/2007, art. 30. Cuando se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero y no se hubieren decretado pruebas o se hubieren negado las solicitadas, la autoridad aduanera dispondrá de cuarenta y cinco (45) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida y para expedir el acto administrativo que decide de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente, contados a partir del día siguiente al cual se radicó la objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento oficial especial aduanero."

El complemento normativo se enmarca en el artículo 519 correspondiente, el cual indica:

"ARTICULO 519 modificado por el artículo 22 del Decreto 4431 de 2004. INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS. "Los términos para decidir de fondo previstos en el presente Capítulo son perentorios y su incumplimiento dará lugar al silencio administrativo positivo. Cuando el procedimiento se haya adelantado para imponer una sanción, se entenderá fallado a favor del administrado..."

Del caso en concreto

Antes de abordar la valoración probatoria en su conjunto, se hace necesario resaltar que la finalidad del proceso disciplinario es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que intervienen. Igualmente, que la decisión que toma el operador disciplinario debe estar fundamentada en las pruebas legal y válidamente incorporadas al proceso, las cuales han sido objeto de análisis para el logro de la motivación de la decisión disciplinaria. Por esta razón, se hace necesario valorar en conjunto las pruebas referidas en el caso particular.

En primer lugar, la documentación aportada en el proceso da cuenta que los señores XXXXX y XXXXX para la época de los hechos eran servidores públicos que desempeñaban sus labores en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, el primero como jefe del Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización y la segunda como Gestor II Nivel 302 Grado 02 del mismo grupo. Para arribar a esta conclusión tenemos la inspección administrativa realizada a la Subdirección de Historias Laborales de la DIAN, donde se obtuvo copia de las actas de posesión, extractos de hojas de vida y la comunicación de funciones.

Una vez determinada su condición de servidores públicos y mediante las copias de la actuación administrativa, el despacho pudo constatar que la División de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, mediante Auto No. 02528 de fecha 09 de noviembre de 2011, ordenó la apertura de la investigación VG 2010 2011 02528, en contra del señor XXXXX, por concepto de estudios de valor (folio 54); investigación que se archivaría con Auto No. 004436 de fecha 06 de diciembre de 2013 (folio 212 al 219).

No obstante, a ser archivado por conceptos de estudio de valor, al momento de la nacionalización de la mercancía, está no correspondía con la descrita en la declaración, situación que motivo la apertura de la investigación por concepto de OPERACIÓN DE CONTRABANADO, dando paso a la apertura del expediente OC 2011 2013 02835 de Fecha 16 de diciembre de 2013 (folio 222).

La anterior afirmación se encuentra plenamente demostrada con el Auto de Apertura No. 02835 de fecha 16 de diciembre de 2013, por medio del cual la Jefe de la División de Fiscalización de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga ordenó la apertura de investigación No. OC2011201302835 en contra de Multiquímicos y/o Jaime Amaya Luis Antonio por operación de contrabando y asignando el expediente a los funcionarios XXXXX y XXXXX, quienes ostentan la calidad de investigadores en la presente actuación.

Se evidencia mediante requerimiento ordinario No. 000449 de fecha 20 de diciembre de 2013 (folio 224), la División de Fiscalización de la Dirección Seccional de Bucaramanga requirió al importador señor XXXXX Y/O XXXXX, para que pusiera a disposición de la DIAN, la mercancía descrita en la declaración de importación No. 2347012644553 del 5 de enero de 2011, y la cual fue descrita como HIPOCLORITO DE CALCIO, en una cantidad de 20 toneladas, requerimiento que fuera entregado a su destinatario el día 23 de diciembre de 2013 (folio 224 Y 226), dando como plazo para la presentación de la mercancía hasta el día 29 de diciembre, fecha en la cual no se hizo entrega de la mercancía solicitada.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-245

Se demostró que el día 31 de diciembre de 2016, el Jefe del GIT de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga profirió Requerimiento Especial Aduanero, por cuanto no le era posible aprehender la mercancía a nombre del importador XXXXX (folio 236241), en virtud a que no se puso a disposición de la DIAN la mercancía relacionada en declaración de importación No. 2347012644553; requerimiento mediante el cual se le otorgó al importador un término de 15 días siguientes a la fecha de su notificación, para presentar respuesta al requerimiento proferido; término que concluiría el día 24 de enero de 2014, fecha en la cual el importador radico ante la DIAN - Nivel Central la respuesta antes aludida (folio 251 al 257). Respuesta que diera paso al Auto No. 201 del 07 de febrero de 2014, mediante el cual se denegaron pruebas (folio 268 al 270).

Por otra parte, el importador XXXXX, el día 08 de enero de 2014 radicó el oficio de fecha 03 de enero de 2014 (folio 178), en el cual manifiesta hacer entrega de 40 kilos de Hipoclorito de Calcio, mercancía requerida por la DIAN, según requerimiento ordinario No. 000449 del 20 de diciembre de 2013, hecho del cual se deja constancia en el acta de hechos No. 5 de fecha 08 de enero de 2014 (folio 279).

Con el objeto de verificar la composición de la mercancía entregada por el importador XXXXX, el funcionario XXXXX, solicita a la Jefe de la Coordinación de los Servicios de Laboratorio de Aduanas de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, la práctica de examen físico químico a las muestras, el día 20 de enero de 2014 (folio 282). Requerimiento del cual se recibió respuesta el día 19 de marzo de 2014 (folio 286), remitida al Doctor XXXXX en calidad de Jefe de la Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, mediante oficio No. 100227343-0091, y en el cual se puede evidencia en la página 8 del documento, que del contenido del mismo se remitió copia al Doctor XXXXX, Jefe Grupo Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario - División de Gestión Fiscalización, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga. XXXXX.

Teniendo en cuenta que el importador presentó respuesta al Requerimiento Especial Aduanero el día 24 de enero de 2014, este despacho pudo establecer que la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales DIAN, tenía hasta el 01 de abril de 2014, para proferir una decisión de fondo sobre la sanción a imponer.

El día 25 de marzo de 2014, el funcionario XXXXX, en calidad de Jefe GIT de investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización DIAN - Bucaramanga, remitió a la Doctora XXXXX Jefe Grupo Operativo Fiscalización DIAN - Bucaramanga, el oficio No. 1-04-238-457-0093, mediante el cual se le da a conocer un análisis de los resultados de las pruebas físico químicas practicadas por el laboratorio de aduanas, y se informa que se debe aprehender solamente y aproximadamente 735 Kg de la mercancía puesta a disposición y que pertenezcan a las muestras identificadas con los números 2014-0034/0035/0036/0037, y en el cual el investigado XXXXX, señala lo siguiente: (folio 293)

"Conforme a la respuesta recibida vía correo electrónico mediante oficio No. 100227343-0091 del 1903-2014, por parte de la Coordinación de los Servicios de Laboratorio de Aduanas de la Subdirección Técnica Aduanera, en relación al oficio No. 14-04-201-238-12 del 20 de enero de 2014, enviado al laboratorio de aduanas, con el fin de solicitar el análisis de unas muestras de mercancía puesta a disposición de la Entidad y que al parecer se trata de Hipoclorito de calcio; se presenta a continuación el siguiente análisis respecto de los resultados obtenidos:"

Anterior pronunciamiento del cual este despacho puede confirmar que efectivamente el funcionario Avendaño Bautista recibió el día hasta el día 19 de marzo de 2014, copia de la respuesta enviada por la Coordinación de los Servicios de Laboratorio de Aduanas DIAN por medio de correo electrónico; hecho que es corroborado igualmente por el correo electrónico aportado por el investigado XXXXX, en audiencia de fecha 05 de diciembre de 2016, en el cual se puede observar que el día 19 de marzo de 2014, sienta las 5:33 p.m., se envió correo electrónico de la cuenta del señor XXXXX, y dirigido a el señor XXXXX, con copia a XXXXX, XXXXX; XXXXX; XXXXX; 2014_10227343; XXXXX, y el cual tiene como asunto 20140319 100227343-0091 Reporte de análisis fisicoquímico de las muestras enviadas con el oficio No. 1-01-201-238-12-000481 de 2014-01-20. (folio 763) Posteriormente y con fecha de 27 de marzo de 2014, los funcionarios XXXXX y XXXXX, profirieron "INFORME REQUERIMIENTO ESPECIAL ADUANERO CUANDO NO ES POSIBLE APREHENDER LA MERCANCIA" en el cual los mencionados realizan una descripción de las actuaciones realizadas en desarrollo de la investigación. (folio 294 al 295)

Por último, el día 31 de marzo de 2014, el funcionario XXXXX, profiere auto de traslado No. 000857 de fecha 31 de marzo de 2014, mediante el cual remite a la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Bucaramanga, el expediente No. OC-2011- 2013-02385, con la finalidad que se continúe con el trámite y se defina de fondo sobre la infracción administrativa, situación con la cual no queda duda alguna para este despacho que los funcionarios investigados a la fecha 31 de marzo de 2014, un días antes de finalizar el termino para que la DIAN tuviera de decidir de fondo sobre los hechos objeto de investigación, sabían que la decisión a proferir era inminentemente una sanción al importador.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-245

El día 29 de abril de 2014, la División de liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga profirió RESOLUCIÓN SANCIÓN CUANDO NO ES POSIBLE APREHENDER LA MERCANCIA No. 001556, de fecha 29 de abril de 2014.

Y no sería hasta el 02 de abril de 2014, cuando llegara el expediente No. OC 2011-2013-000234, a la División de Gestión de liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bogotá para que continuara el trámite, según planilla Múltiple de Remisión No. 353 (folio 634), ya encontrándose vencido el termino para que la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, se pronunciara de fondo sobre la sanción a imponer al señor XXXXX Y/O XXXXX.

Para finalizar obra en el expediente disciplinario de la referencia Acta de reparto No. 9, de fecha 03 de abril de 2014, en la cual este despacho puede evidenciar que no es hasta esta fecha que a la funcionaria XXXXX de la División de Gestión de Liquidación, se le asigna expediente del señor XXXXX Y/O XXXXX, para el tramite pertinente de esa División.

Ahora bien, este Despacho debe establecer si las conductas de los XXXXX y XXXXX vulneraron el precepto de carácter disciplinario establecido en el numeral 35 del Artículo 48 de la Ley 734 de 2012. Para este fin, es importante aclarar que comete esa falta disciplinaria quien da lugar al silencio administrativo positivo, atendiendo las circunstancias nocivas que este efecto jurídico genera para la administración.

En este contexto, es comprensible que si en esa actuación administrativa se pretendía establecer el tipo de mercancía para poder continuar con la investigación aduanera, se hiciera necesario establecer si la misma correspondía a Hipoclorito de Calcio o, por el contrario Cloruro de Calcio, pues la consecuencia jurídica sería distinta en cada uno de los casos anteriores. En este contexto, es razonable que esta mercancía fuera enviada al servicio de Laboratorios de Aduanas, para que fueran expertos en el tema quienes realizaran un análisis físico químico y así determinar. Nótese que el análisis técnico era necesario para adelantar la correspondiente aprehensión y así continuar con el proceso de definición jurídica.

Sobre esta temática es muy revelador que el día 20 de enero de 2014, el jefe del Grupo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, remitió mediante el Oficio N. 1-04-201-238-12 la solicitud para la elaboración del análisis físico químico, dejando a disposición la mercancía en las bodegas de la Almacенadora Almagrario S.A., ubicadas en el Kilómetro 3 Vía Palenque Café Madrid de la ciudad de Bucaramanga.

Esta postura es confirmada con el Oficio suscrito el 19 de marzo de 2014 por el Investigador Químico de Aduanas XXXXX (Folio 286), donde remite el respectivo reporte del análisis físico químico practicado a 28 muestras, concluyendo que contienen hipoclorito de calcio, cloruro de sodio, hidroxiclорuro de calcio y carbonato de calcio. Cabe resaltar que este oficio fue remitido por correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2014 a las 5:33 p.m.

Así las cosas, del día 20 de marzo de 2014 al 1° de abril del mismo año (fecha en que operó el silencio administrativo positivo), se generaron distintas actuaciones por parte de los funcionarios Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización, tales como el 25 de marzo remitieron a la jefe del Grupo Operativo de Fiscalización los resultados del laboratorio para que procediera a la aprehensión de la mercancía; el 27 de marzo se realizó el informe del requerimiento especial aduanero, con el objeto de remitirlo a la División de Gestión de Liquidación, así como el Auto de Traslado No. 000857 calendado 31 de marzo de 2014, por medio del cual remite el expediente a la División de Gestión de Liquidación para que decidiera de fondo sobre la infracción administrativa.

Como conclusión, podemos afirmar que en el presente caso efectivamente operó el silencio administrativo positivo; sin embargo, atendiendo que en tratándose de derecho sancionador y particularmente en derecho disciplinario está proscrita toda clase de responsabilidad objetiva, pues el Artículo 13 de la Ley 734 de 2002 establece: <<Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda falta de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa>>.

En razón a este criterio jurídico, este despacho considera que no puede realizarse reproche disciplinario a los funcionarios investigados pues con su actuar no se transgredió el ordenamiento disciplinario que le competía observar ya que, se itera, el silencio operó en gran parte porque era necesario la realización del análisis físico químico de la mercancía. No se logra visualizar que este fenómeno jurídico haya acaecido porque el actuar de los funcionarios se logre adecuar en alguno de los factores generadores de culpa o por una violación al deber objetivo cuidado y mucho menos en su actuar se establezcan los elementos constitutivos de la modalidad dolosa.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-245

Así las cosas, teniendo en cuenta que si falta alguna de las categorías dogmáticas (tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad) no existe falta disciplinaria, en el presente caso la conclusión no puede ser otra que el actuar de los funcionarios investigados no constituye falta disciplinaria porque este operó también por circunstancias ajenas a su voluntad.

En estas condiciones y en concordancia con las pruebas allegadas a la actuación, los funcionarios deben ser exonerados de responsabilidad disciplinaria y sí se ordenará en la parte resolutive de la presenta actuación. En mérito de lo expuesto, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias,

RESUELVE

PRIMERO: ABSOLVER DEL CARGO FORMULADO en el auto de citación a audiencia No. 1741200016 del 24 de octubre de 2016, proferido por esta Subdirección de Investigaciones Disciplinarias en contra del señor XXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXX expedida en Bucaramanga y XXXXX, identificado con la cédula de XXXXX expedida en Bucaramanga, con fundamento en las razones señaladas en la parte motivada de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR en estrados la presente decisión al Doctor XXXXX, a la Doctora XXXXX y a los investigados XXXXX y XXXXX, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 de la Ley 734 de 2002, a los sujetos procesales. Contra la presente decisión, procede el recurso de apelación al tenor de lo establecido en el artículo 180 de la Ley 734 de 2002.

TERCERO: En firme la presente decisión, COMUNICAR a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 174 del Código Disciplinario Único.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,



JORGE ADRIANO MORENO PONCE
Subdirector de Investigaciones Disciplinarias
UAE Agencia ITRC